

1502522-93.2021.8.26.0161

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Jogo de azar

Magistrado: CECÍLIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... que a denúncia envolvia somente o tráfico de drogas, sendo as máquinas encontradas por acaso.

No mesmo sentido, a testemunha André da Silva Cardoso, também policial civil, narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, foram checar uma denúncia de tráfico de drogas e, no local, localizaram drogas, além de 19 máquinas caça-níqueis desligadas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

1ª Vara Criminal

Av. 7 de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502522-93.2021.8.26.0161 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502522-93.2021.8.26.0161 2021/001526

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Jogo de azar

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

JOSÉ ROBERTO MACHADO DE SOUZA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CECILIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Vistos.

JOSÉ ROBERTO MACHADO DE SOUZA, qualificado às fls. 15 e 18, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 50, § 3º, alínea "a", da Lei das Contravenções Penais (Decreto - Lei nº 3.688/41), porque, no dia 09 de setembro de 2021, por volta das 19h35min, na Rua dos Tabajaras, nº 147, Piraporinha, nesta cidade e Comarca de Diadema, explorava, em local acessível ao público, jogo de azar em que o ganho ou perda dependem exclusivamente da sorte.

Em manifestação de fls. 31, o Ministério Público requereu a juntada das folhas de antecedentes e certidões do denunciado para verificação do cabimento de transação penal.

Ante a existência de antecedentes, o Parquet ofereceu denúncia (fls. 01/03).

Citado às fls. 106, realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento, por meio de teleaudiência, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, ocasião em que o denunciado apresentou resposta à acusação, sendo recebida a denúncia. No mais, foram ouvidas as testemunhas e interrogou-se o réu, prosseguindo-se com os debates orais entre as partes. Salienta-se que o denunciado constituiu Patrono para o ato. Em alegações finais, resumidamente, a D. Representante do Ministério Público requereu a procedência do pedido, eis que restaram comprovadas a materialidade e

autoria delitivas, indicando ainda que o fato das máquinas estarem desligadas, no caso concreto, não era situação apta a descaracterizar a conduta, eis que foram encontrados valores dentro das máquinas, bem como que eram 19 máquinas. No tocante à dosimetria, pugnou pelo regime inicial aberto, eis que o réu é tecnicamente primário.

Já a D. Defesa, em suma, pugnou a absolvição, pela fragilidade probatória, aduzindo que não há provas para a condenação, eis que as máquinas estavam desligadas, não havendo prova que havia exploração de jogo, inclusive porque os policiais não encontraram nenhum jogador no momento, havendo também apenas R\$ 61,00 reais, quantia esta que seria irrisória levando em consideração que foram encontradas 19 máquinas no local. No mais, indicou que o artigo 50 da Lei de Contravenções Penais não foi recepcionado pela Constituição de 1988. Por fim, em caso de condenação, pugnou pela aplicação da pena-base no mínimo legal, pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, pela substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos requerendo ainda o reconhecimento do direito do réu de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, em que pese a alegação de não recepção do artigo 50 da Lei de Contravenções Penais pela Constituição Federal alegada pela D. Defesa, não há que se falar em não recepção de tal previsão legal, eis que, entendendo que a tipificação legal encontra guarida na proteção da saúde pública relativamente ao jogo patológico, que, muitas vezes, deixa o indivíduo em verdade miséria, atingindo sua dignidade. Assim, embora haja repercussão geral reconhecida sobre o tema, não foi suspensa a aplicação do dispositivo em tela, tampouco foi decidida a questão pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Logo, enquanto não decidida de maneira definitiva a não recepção alegada, continua vigente a contravenção penal referente à exploração de jogo de azar. Neste sentido:

Apelação Criminal. Jogos de Azar. Atipicidade afastada. Independe as máquinas caça-níquel estarem ligadas ou não, já que a conduta delituosa se subsume com o estabelecimento das máquinas caça-níquel. Não recepção do artigo 50, das contravenções penais. Afastado. Jurisprudência que acolhe o tipo, nos termos constitucionais. Suspensão do processo até a resolução do Tema 924, de repercussão geral do STF. Afastado. Ausência de ordem expressa. Sentença reformada para substituir a pena privativa de liberdade por multa. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - APR: 00016698620178260101 SP 0001669-86.2017.8.26.0101, Relator: Fernanda Teixeira Salviano da Rocha, Data de Julgamento: 27/08/2020, 2º Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 27/08/2020). Grifo nosso.

No mais, presentes os pressupostos processuais. Ausentes nulidades a sanar ou demais preliminares a analisar, passo ao mérito.

O conjunto probatório constante dos autos demonstra a veracidade dos fatos narrados na denúncia, com a necessária segurança e certeza, para que seja julgado procedente o pedido condenatório.

A materialidade delitiva restou sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13), pelo laudo pericial do local com fotografias (fls. 41/46) e pela prova oral.

Também a autoria restou devidamente comprovada. Senão vejamos.

Interrogado em Juízo, negou a autoria dos fatos narrados na inicial acusatória. Relatou que alugava o espaço, mas não era ligado ao jogo, que recebia R\$ 500,00 reais por quinzena, mas o jogo não fazia parte do seu comércio. Esclareceu que o nome do indivíduo para quem alugou era João, que ele mandava que terceiro fizesse serviços no local, indicando que o João não passou o seu endereço para ele. Não conhecia os policiais antes dos fatos. Indagado, contou que locava o espaço devido à Pandemia que fez cair o movimento. No mais, indicou que teve umas três passagens anteriores pelo mesmo fato, indicando que pagou cesta básica por um deles e que também estava assinando no Fórum uma suspensão condicional do processo também pelo mesmo fato.

A negativa do réu, entretanto, restou isolada nos autos. Vejamos:

Em depoimento bastante seguro, a testemunha Lucas Barbatí Santurbano, policial civil, informou que se recordava dos fatos. Contou que foram checar uma denúncia de

tráfico de drogas no bar, com venda de cocaína no período noturno. Chegando ao local, encontraram drogas atrás do cesto de lixo e, em uma parte do bar, 19 máquinas caça-níqueis que eram acessíveis ao público. No mais, indicou que foi encontrado por volta de R\$ 60,00 reais. O dono do bar, ora denunciado, informou que alugava para terceiros o local em que ficavam as máquinas, não dando dados qualificativos do terceiro. Não conhecia o denunciado antes dos fatos. Indagado, afirmou que as máquinas estavam desligadas, mas foram ligadas e funcionavam, sendo 19 máquinas, indicando que o ora averiguado não dei justificativa para a quantidade de máquinas. Por fim, esclareceu que a denúncia envolvia somente o tráfico de drogas, sendo as máquinas encontradas por acaso.

No mesmo sentido, a testemunha André da Silva Cardoso, também policial civil, narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, foram checar uma denúncia de tráfico de drogas e, no local, localizaram drogas, além de 19 máquinas caça-níqueis desligadas, numa parte reservada, não havendo nenhum jogador no local. Informou que, quando ligadas pelo perito, as máquinas funcionavam normalmente e foi encontrado o valor de R\$ 61,00 reais em seus noteiros. Indagado, disse que o pessoal que adentrava a parte do bar tinha acesso as máquinas. No mais, o proprietário do estabelecimento é o ora averiguado que informou que alugava a parte para uma terceira pessoa, sabendo da ocorrência do jogo, eis que de fácil visualização, não indicando maiores qualificações do terceiro

Cabe ressaltar, nesse passo, que as palavras dos policiais militares, que atuaram de maneira tão direta, não podem ser relevadas ou consideradas suspeitas apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhe depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras justamente quando presta contas de suas diligências.

Assim, verifica-se que, na data dos fatos em tela, policiais civis receberam denúncia anônima dando conta de que havia um indivíduo vendendo entorpecentes em restaurante situado no mencionado endereço e para lá rumaram. De fato, naquele estabelecimento, de propriedade do réu, os policiais encontraram entorpecentes e, também, em local acessível ao público, 19 máquinas conhecidas como “caça-níqueis” totalmente aptas ao funcionamento e com R\$ 61,00 em espécie em seus noteiros. Assim, restou bem caracterizado que JOSÉ auferia lucros com a exploração do jogo. Saliento que o auto de exibição e apreensão de fls. 13 e o laudo pericial com fotografias do local dos fatos de fls. 41/46, não deixam dúvidas acerca da apreensão de dezenove máquinas caça-níqueis, desligadas, mas que quando em funcionamento exibiam os jogos “Halloween”, “Dallas”, “Bichos” e “Bucaneiros”, com o valor de R\$ 61,00 (sessenta e um reais) em seus interiores.

No mais, o laudo pericial de local indicado deixou claro que: “Foi realizado o exame de funcionamento das máquinas no local. Os equipamentos examinados apresentavam-se como sorteadores de resultados, nos quais, o ganho ou perda, independem da habilidade física ou mental do agente, ou seja, dependem exclusivamente da sorte (“Jogo de Azar”), restando assim comprovada a materialidade da contravenção penal prevista no artigo 50, § 3º, alínea “a”, da Lei das Contravenções Penais (Decreto - Lei nº 3.688/41), independentemente das máquinas estarem desligadas no momento da abordagem policial. A propósito:

Jogo de Azar. Máquinas Caça-Níquel encontradas no estabelecimento (bar) do réu. Máquinas desligadas no momento da apreensão. Irrelevância. Perícia que constatou serem aptas à exploração e que, embora não tivesse sido encontrado numerário dentro das máquinas, foi constatado registro estatístico de entrada e saída de dinheiro do maquinário. Depoimentos dos policiais em assonância com a confissão do réu, embora este alegasse escusa de que não teria ligado as máquinas e que estas teriam sido deixadas em seu estabelecimento por terceira pessoa. Sentença bem fundamentada. Ausência de Nulidade. Autoria e materialidade comprovadas. Justeza da sentença condenatória. Recurso defensivo não provido. (TJ-SP - APR: 15063643520198260005 SP 1506364-35.2019.8.26.0005, Relator: José Luiz de Jesus Vieira, Data de Julgamento: 19/08/2021, 5ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 19/08/2021). Grifo nosso.

Anoto, apenas, que embora o réu tenha dito que o espaço era locado, não conseguiu

apontar quem seria o locador ou mesmo qualificá-lo, ficando evidente sua ligação com o jogo do azar, até porque já condenado por esta prática anteriormente. Nessas condições, a condenação do réu nos termos da exordial acusatória é a medida que se impõe.

Passo, então, à dosimetria da pena, de forma individualizada, com observância ao princípio da humanidade, nos termos do art. 5º, XLVI da CF/88 e arts. 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro.

Considerando as disposições do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu não ostenta maus antecedentes (fls. 35/36 e 102/104). Ademais, culpabilidade normal ao tipo; ausentes elementos para aferir personalidade ou conduta social; motivos, circunstâncias e consequências próprios da conduta. Assim, fixo a pena-base no piso legal, ou seja, em 03 (três) meses de prisão simples e 10 (dez) dias-multa. O dia-multa será à razão mínima, ante a falta de informações acerca das condições financeiras pessoais do réu.

Na segunda etapa, ausentes atenuantes ou a considerar. Verifico, contudo, a presença da agravante da reincidência específica - art. 7º da Lei das Contravenções Penais - (fls. 35/36 e 102/104 - autos nº 0010451-96.2017.8.26.0161 referentes à execução nº 0006486-42.2019.8.26.0161). Assim, majoro a pena na proporção de 1/6 (um sexto), passando a totalizar 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples e o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento ou de diminuição a considerar, torno definitivas as penas nos patamares em que se encontravam.

O regime inicial de cumprimento de pena, a teor do art. 33 do Código Penal, será SEMIABERTO, em observância ao quantum de pena aplicado, tendo em vista se tratar de réu reincidente específico. Sendo assim, tudo indica que a fixação de regime mais brando não seria suficiente à repressão e prevenção da contravenção.

Consigne-se que, pelas mesmas razões, se mostra inviável a substituição da pena artigo 44 do Código Penal) ou a concessão do sursis (artigo 77 do Código Penal). No mais, a reincidência específica do réu demonstra que tais medidas não seriam socialmente recomendáveis e nem suficientes para coibir a prática de novas contravenções.

Ademais, impossível, ainda, aplicar o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, pois o réu respondeu ao processo em liberdade.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO o réu JOSÉ ROBERTO MACHADO DE SOUZA à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime semiaberto, e o pagamento de 11 (onze) dias-multa no valor unitário mínimo legal, por se achar incurso no artigo 50, §3º, do Decreto-lei 3688/41.

Como respondeu solto a este processo, defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois não estão presentes os requisitos necessários à decretação de sua prisão cautelar.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, observando-se o disposto no art. 4º, §, 9º, "a", da Lei Estadual 11.608/03 e art. 98, §3º, alínea "a", do CPC, que não abrangem valores eventualmente já depositados nos autos.

Ademais, em relação ao valor apreendido R\$ 61,00 reais (auto de exibição e apreensão de fls. 13 e comprovante de depósito de fls. 29), sendo produto da prática do delito, decreto seu perdimento em favor da União.

Por fim, autorizo que os objetos relacionados à exploração de jogo de azar (auto de exibição e apreensão de fls. 13) sejam destruídos.

Publique-se. Intimem-se.

Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA